PROJET DE SAUVETAGE :
LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE ESPORTIF

Habbine Estelle KIM[1]
Avocat (Paris & New York)

ABSTRAIT

Le présent article examine le contrat à durée déterminée esportif (« CDD esportif ») créé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique afin de déceler les avantages et défis afférents à son application. De diverses possibilités de réformes législatives sont considérées en vue d'une instrumentalisation plus répandue du CDD esportif en pratique. En termes généraux, une mise en balance entre un régime souple et une protection adéquate, ainsi que la promotion d'un dialogue transfrontalier entre les acteurs de l'esport, semblent nécessaires pour trouver une solution d'intérêt commun dans le marché globalisé de l'esport.

Mots clés : esport, droit social, contrat de travail, contrat de prestation de services, réforme

[1] Avocat international inscrit aux barreaux de Paris et de New York. Associé du cabinet d'avocats Archè SELARL (habbine.kim@archelegal.com). LLB (University College London). Master en Droit, économie, gestion, mention Droit européen (Paris 1 Panthéon-Sorbonne). "Expert juridique" (Station F - HEC Incubator). Gouverneur regional (France) de l'association internationale des avocats coréens (International Association of Korean Lawyers). Membre du comité consultatif de l'institut du droit européen (European Law Institute).

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4125169

INTRODUCTION

Avant de comprendre les atouts et les failles du contrat à durée déterminée esportif (« CDD esportif »), qui est autonome et dérogatoire au régime commun, il convient de rappeler les généralités du droit social en France.

I. Le droit social en France

La France est notoire pour son avancement en la matière de protection sociale. Régi par le droit public et privé, le droit social en France regroupe l'ensemble des règles sur les relations individuelles et collectives de travail : le droit du travail, le droit de la sécurité sociale et de la mutualité et le droit de l'action sociale de l'État.

Un contrat de travail est soumis au Code du travail, au Code de la sécurité sociale et au droit commun. Hormis des cadres plus spécifiques à certaines professions, projets et statuts, les contrats de travail en France se divisent de manière générale en deux principaux types de contrats : le contrat à durée indéterminée (« CDI ») et contrat à durée déterminée (« CDD »). Un critère clé demeure l'existence d'un **lien de subordination**.

Il se distingue d'un contrat de prestation de services qui est soumis au Code civil, au Code de commerce et au droit commun. Classifié sous les notions de « contrat d'entreprise » ou de « louage » (Titre VIII du Code civil), un contrat de prestation de service se caractérise principalement par l'existence d'une **autonomie**.

Contrairement aux notions de contrats à durée déterminée dans les juridictions *common law* aux Royaume Uni, Canada, Australie et Etats-Unis (connus de manière générale sous la dénomination « *fixed-term contract* »), un CDD français **s'applique par exception au régime normal d'un CDI.** Par ailleurs, un CDD est soumis à des **conditions strictes d'application**, tant en termes de la **durée** qu'en termes de son **contexte** et **objet**.

II. Observations sur le CDD esportif en France

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique consacre, dans son Article 102, une disposition créatrice d'un contrat de travail à durée déterminée spécifique aux joueurs professionnels salariés de jeux vidéo compétitifs.

L'applicabilité de cette disposition est soumise à quatre conditions initiales :

1. Le joueur est un joueur **professionnel** ;

2. Le joueur est **salarié** dans le sens du droit social en France ;

3. La structure (la société ou l'association Employeur) doit être **agréée** ; et

4. Le contrat s'inscrit dans le cadre spécifique et limitatif d'un jeu vidéo **compétitif dans le sens du Code de la sécurité intérieure.**

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4125169

Certaines observations peuvent être faites :

- En l'état, il s'agit d'un instrument unique dit « *standalone* » sur l'esport en France.

- La définition d'un « joueur professionnel » n'est pas fournie par la loi en dehors du contexte de la relation salariale avec une structure agréée. Cela semble exclure ou du moins ne pas différencier les joueurs semi-pros ou les joueurs indépendants participant aux jeux vidéo compétitifs seuls, sans lien de rattachement avec quelconque structure agréée. Il demeure incertain si le législateur avait l'intention que cette qualification soit déterminée par un **standard de l'industrie** ou s'il s'agit simplement d'un **terme descriptif** sans définition ni signification juridique qui s'avère attaché aux deux autres conditions d'un salarié (1) qui participe à des compétitions de jeux vidéo compétitifs (2).

- Il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée spécial et distinct du CDD dans le sens du régime commun. Le Code de travail s'applique, sauf précision du contraire par la loi. En cas de méconnaissance des règles de forme ou de fond afférents au CDD esportif, il existe un risque de requalification en un CDI. Le travailleur demeure ainsi protégé à un certain degré, contrairement à certaines juridictions *common law* où la conversion du CDD en CDI peut être éradiqué par une convention collective.

- Il s'agit d'un contrat à durée déterminée dont la durée minimale est d'un (1) an, avec deux dérogations strictes prévues en cas de remplacement d'un joueur professionnel absent ou suspendu, ou lorsque le contrat court au minimum jusqu'au terme de la saison. La durée maximale est de cinq (5) ans avec la possibilité de renouvellement indéfini sans délai de carence, ni d'indemnité de précarité obligatoire.

- L'employeur nécessite un agrément. D'une part, ce système accorde une certaine reconnaissance, une crédibilité et un crédit aux employeurs sérieux qui ont fait des efforts au niveau des déclarations, des obligations de transparence et de responsabilités suivant son agrément. Cela pourrait aussi contribuer à la création d'un point de référence pour les joueurs, notamment les mineurs et leurs représentants légaux, qui souhaiteraient s'assurer un certain niveau de confiance et de légitimité de la structure qu'il envisage rejoindre. D'autre part, il n'existe pas actuellement d'avantage concurrentielle ou d'exemption fiscal aux structures agréées, hormis la possibilité d'utiliser un CDD esportif. Du point de vue des acteurs, il demeure l'option alternative de procéder sans agrément donc sans formalités ni contrôle par les autorités par un contrat de prestation de services (utilisé de la manière la plus répandue en pratique). Par ailleurs, les agents jouissent d'une flexibilité large quant à leurs rôles et ne sont pas soumis à des conditions d'autorisation ou de certification.

III. Le décalage avec la réalité et les défis aux acteurs dans l'industrie de l'esport

La France est l'un des pays à avoir consacré explicitement une disposition juridique spécifique à l'esport. Malgré cette initiative ambitieuse, il existe une certaine discordance entre les textes de loi actuels et la réalité de la pratique esportive, tenant compte du cadre mondial dans lequel il s'inscrit.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4125169

S'il existe très peu de contentieux visible à ce jour en matière de droit social concernant le CDD esportif en France, alors que la loi pour une République numérique date de 2016, les raisons peuvent être nombreuses. Soit les acteurs ne savent pas comment exploiter et appliquer cet instrument de manière à refléter efficacement leurs intérêts ou les risques liés à cet instrument qui existent de manière isolée des autres considérations importantes demeurant dans le vide juridique (la fiscalité, les compétitions en ligne, les conventions collectives) n'outrepassent pas les opportunités. Sans être reconnue et adoptée par un certain nombre de groupes au sein l'industrie, il semble peu probable que cette option soit exploitée par un ou deux acteurs qui oserait jouer avec le hasard, ou même d'y tenter *ab initio*. En tout état de cause, ce nouvel instrument semble loin de pouvoir être l'objet d'instrumentalisation en l'état.

Cette discordance est percutante même en dehors des considérations pratiques afférentes aux coûts, aux charges et aux impôts.

Bien que l'esprit de la loi ainsi que les cultures, les traditions, la moralité et les valeurs afférents à l'Etat qui l'édictent ont vocation à être protégés et préservés à certains égards, il convient de les adapter dans le cadre spatiotemporel dans lequel ils s'inscrivent.

Dans un cadre numérique dynamique et sans frontières, un régime juridique qui prend en compte les instruments déjà existants dans les pays *common law* ou d'autres Etats civils du droit de l'Union dès sa conception serait mieux positionné pour mettre en valeur son exportabilité et extraterritorialité sur le plan mondial.

En effet, les particularismes juridiques sont susceptibles d'engendrer des obstacles au niveau de la concurrence à l'échelle internationale, les acteurs du marché favorisant un régime accessible, familier, flexible et efficace en termes de coût et de temps. Considérant les relations internationales qui se nouent et se concrétisent par la mobilité, le transfert, le détachement, le prêt et le recrutement local des talents étrangers, un régime général plus souple serait plus efficace et désireux qu'un régime protectionniste.

Un renforcement de régimes particularistes risque d'inciter le *forum shopping* en la matière de droit privé international. Le *forum shopping* s'agit d'une pratique consistant à élire le Tribunal compétent en fonction de la loi la plus favorable aux intérêts de la partie qui le réclame, et non nécessairement en fonction de sa pertinence. Non seulement elle est susceptible de remettre en cause l'intention des parties *a posteriori* dans le cadre d'un éventuel contentieux, mais elle risque aussi de porter atteinte à la sécurité juridique.

Situés entre le vide juridique, la diversité des dérogations et interprétations selon l'Etat, les spécificités liées à l'industrie de l'esport et les difficultés de langue (tant du point de vue des investisseurs et des acteurs étrangers que du point de vue des juridictions étrangères qui pourront être menées à considérer le droit français lorsqu'il s'avère pertinent dans le cadre d'un contentieux), les acteurs seraient incités à concourir pour trouver un régime simple et rapide qui marche en suivant le bruit du succès dans les juridictions où les choses semblent possibles.

Afin de mettre en exergue les avantages du régime social en France qui, malgré les nombreux coûts et obligations, assurent un certain niveau de protection et de sécurité aux travailleurs, et ainsi de confiance publique, il convient d'adapter les dispositions actuelles afin de faire la même chose, mais *autrement*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4125169

IV. Des réflexions sur la réforme

En vue de ce qui précède, la nécessité d'une réforme paraît naturelle. Or, quelques questions demeurent essentielles à considérer : quelles parties des dispositions actuelles pourraient être réformées et comment ? Les possibilités et les solutions sont bien nombreuses.

1. La création d'un instrument hybride d'intérêt commun

Certaines juridictions *common law* perçoivent le contrat de travail comme un type de contrat commercial et applique le droit commercial et le droit commun des contrats. Tenant compte de l'élément commercial des accords pouvant rentrer dans la sphère du CDD esportif, une solution pourrait consister à **appliquer certaines dispositions du code civil et du code de commerce au CDD esportif**.

L'importation des conditions de bonne foi, de proportionnalité et d'information (voire de langue si un élément international ou de non-discrimination sont en jeu) **susceptibles d'être sanctionnés** (par des dommages et intérêts ou une requalification en CDI) pourrait apporter certaines solutions. Ces principes pourraient s'appliquer tant lors des négociations précontractuelles (e.g. ajouter la condition d'octroi d'une « période de réflexion raisonnable » avant la signature d'un contrat) que pendant toute la durée du contrat.

Ensuite, si une **négociation à pleine concurrence** était obligatoire, les contractants prendraient le temps nécessaire pour discuter et faire réflexion avant de décider de s'engager sérieusement dans leurs projets d'intérêt commun. Une condition pour formaliser le contenu et les résultats des négociations par tous moyens écrits, avant chaque conclusion, modification et renouvellement du CDD esportif, mis à disposition des parties à tout moment et préservé pendant une période déterminée à compter de l'expiration de la durée contractuelle y compris les renouvellements, inciterait un dialogue équilibré entre les contractants.

L'idée provient de la nécessité de protéger les joueurs professionnels, souvent jeunes, des pratiques commerciales agressives afin d'obtenir leur consentement.

Par exemple, « *qui ne dit mot ne consent pas* ». Certes, la preuve demeure libre pour les faits juridiques en droit civil français. Elle est libre, voire « loyale » ou « proportionnelle » en la matière prud'hommale. Cependant, lorsque les négociations ont lieu verbalement par usage ou pratique de l'industrie, lorsque le joueur a deux jours pour décider de signer le contrat avant que l'offre expire, comme cela a été le cas pour le jeune joueur professionnel de *Overwatch* Jeffrey "blasé" Tsang, il y a un besoin d'une protection *ex ante* la phase de la signature du contrat en faveur de la partie la plus faible, qui peut-être *ne dit mot* en raison de l'ignorance, de la pression ou de peur.

Sur ce sujet, il existe en *common law* des régimes protecteurs du contractant (souvent la partie la plus faible) tels que le « *duress* » ou le « *undue influence* », **afin de sanctionner les pratiques de pression, coercition et d'intimidation injustifiée, contraire à la libre volonté (« *free will* ») de quelqu'un**. Au-delà de l'élément substantiel et de la forme du contrat en cause, l'enjeu de ces « remèdes en équité » (« *equitable remedy* ») est de garantir à ce que les actes et les paroles antérieurs à la signature du contrat qui lient les parties ne soient pas entachés de vice de consentement difficile à prouver ou passés outre une fois que les relations se matérialisent dans la durée (*par ex.* acceptation

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4125169

tacite). Néanmoins, l'équité demeure une exception qui est analysé au cas par cas et ne pourrait constituer une base juridique ou un principe applicable de manière systématique.

Les notions les plus proches de dol et de violence en droit civil (qui ne s'appliquent pas aux contrats de travail tel que le CDD esportif) nécessitent des actes (*des manœuvres, des mensonges, une dissimulation intentionnelle d'une information déterminante, un exercice de pression ou de contrainte*), voire des craintes liées à l'atteinte aux choses déjà existantes (*d'exposer la personne, la fortune ou celles des proches à un mal considérable*).

Ces notions ne pourront couvrir les cas de pression commerciale par la création artificielle d'un sentiment de perte de chance afin d'induire le joueur professionnel à signer le contrat.

Ce faisant, un régime hybride et une promotion de dialogue entre les acteurs seraient de valeur à l'industrie de l'esport qui touche beaucoup de jeunes. Ces derniers, amenés potentiellement à négocier avec des professionnels plus expérimentés dans une langue étrangère ou dans une langue technique, sans nécessairement avoir les moyens ou la conscience des risques et de ses droits, devraient bénéficier d'une protection juridique.

Une réforme avec une attention particulière sur une éventuelle *obligation* de négociation (précontractuelle, *ex ante* chaque modification et/ou renouvellement du CDD esportif) contribuerait à la promotion des échanges de bonne foi et à pleine concurrence entre les contractants.

2. La création des avantages concurrentiels aux structures agréées

Parallèlement à ce qui précède, la création des dérogations partielles du régime du droit social (e.g. la possibilité de choisir volontairement la prise en charge des charges et de l'assurance) permettrait plus de flexibilité au contenu et les modalités d'opération du CDD esportif.

Afin d'inciter les structures agréées et agents à adopter une pratique commerciale loyale face à la concurrence mondiale, des avantages ou exemptions fiscales, des crédits d'impôt ou des régimes d'impositions plus favorables (e.g. un traitement différencié/global des compétitions esportives des autres activités accessoires comme l'exploitation des images) sont aussi envisageables.

En tout état de cause, il convient de tenir compte du fait que l'industrie de l'esport et l'esport ne s'arrête pas à l'organisation des jeux vidéo compétitifs, ni aux joueurs professionnels.

Les structures au sein desquels les joueurs professionnels de l'esport appartiennent sont dotées de personnels importants en charge de l'administration, le marketing, le recrutement, l'entraînement, les relations externes et internes, parmi d'autres.

En l'absence d'un régime juridique qui viendrait en support de l'industrie de l'esport et des acteurs dans l'ensemble, ces derniers auront des difficultés à entretenir des relations saines et durables et à contribuer à la création d'un écosystème avec un réel potentiel économique. Les mesures d'aides susvisées encourageraient une pratique de bonne foi et une concurrence loyale des acteurs souvent bénévoles sous contrainte d'un budget limité pour toutes ses activités et personnels. En tout état de

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4125169

cause, il convient d'assurer un certain niveau de cohérence entre les différents mécanismes juridiques afin que chaque instrument puisse être exploitable à sa propre manière utilement et efficacement.

3. Sur la simplification des dispositions sur la durée et le temps de travail

Dans un marché dynamique et évolutif sujet à des changements et adaptations au fil du temps, une *lex generalis* (néanmoins dédiée pour l'industrie spécifique de l'esport) pourrait s'exploiter plus largement qu'une *lex specialis* exclusive et limitée en termes de l'industrie, la matière, le contexte et bénéficiaires.

Par exemple, l'esport étant situé entre une profession (jouer pour s'entraîner) et le loisir (jouer pour le divertissement personnel et le plaisir), il s'avère difficile de comptabiliser et contrôler « les heures de travail » et de les distinguer des heures de pure divertissement ou d'activité personnel mais lié. Le système de forfait jours ne semble donc pas entièrement adapté.

En l'absence d'une convention collective nationale dédiée aux acteurs de l'esport, ou des dérogations spéciales afférentes aux heures de travail, le contrat de prestation de services demeure le plus adapté à la réalité en pratique qu'un CDD esportif en l'état.

Dans certaines juridictions *common law*, des contrats « *casual* » ou « *zero hour* » garantissent plus de flexibilité quant aux heures de travail et de son organisation. Ils sont plus adaptés pour les types de travail *freelance* ou sur demande, pour lesquels le nombre d'heures de travail et sa fréquence dans une certaine période seraient irréguliers, indéterminables d'avance, ou dépendant du projet, de la disponibilité ou de la volonté du travailleur. Ces types de contrats peuvent être perçus comme étant « hybride » dans le sens où ils se situent entre un contrat de travail, avec différents degrés de garantie et de protection sociale, et un contrat de prestation de services dont le régime serait assimilable à celui du « *independent contractor* » du moins en termes de l'autonomie et l'indépendance du travailleur.

Il convient de songer à laisser **l'obligation de contrôle de temps à la charge des joueurs professionnels** et créer une **exemption sur les heures supplémentaires ou le plafond sur les heures de travail**. Cela résulterait à un rapprochement du CDD esportif à un contrat de prestation de services afin de rendre cet instrument unique plus attractif à ses bénéficiaires.

En parallèle, afin de préserver la santé des joueurs professionnels et prévenir des cas d'abus, des **obligations plus strictes pourraient être imposées à la charge des employeurs relatives au contrôle de santé, d'information et d'organisation du travail**, ainsi qu'une **obligation d'un certain temps et période de repos en dehors des congés payés**. De plus, l'obligation de préciser le montant d'une **rémunération en contrepartie d'une mission objectivement déterminée** (et non un résultat ou les heures de travail) pourrait s'imposer.

Si l'usage du CDD esportif comprend les activités accessoires telles que l'entraînement, une précision sur la durée déterminée **sans précision sur la durée minimale** et sur les modalités de renouvellement accorderait plus de flexibilité aux contractants dans des circonstances exceptionnelles en raison de leur statut ou la nature des jeux vidéo compétitifs en cause.

Effectivement, les précisions dans la formulation des conditions ou d'interdictions pourraient impliquer la nécessité de réajuster la liste d'éventuelles dérogations et exemptions (si elle n'est pas

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4125169

exhaustive), rendant les textes de loi plus complexes à appliquer en pratique. Ainsi, ce type de simplification pourrait aider à englober un plus large éventail de cas, ajustables selon les circonstances. Avec ce type de changement, l'ajout d'une **interdiction d'une clause de renouvellement automatique** à l'échéance de chaque durée contractuelle préviendrait des cas d'abus afin de se soustraire des obligations qui s'imposeraient aux parties en cas de requalification.

Si l'usage du CDD esportif devait être restreint aux compétitions de jeu vidéo, à l'exclusion des activités accessoires, **une durée semblable à celle prévue par un CDD à objet défini s'achevant à la fin de la mission** pourrait être efficace et flexible.

Enfin, une **clause d'exit (« *Exit Clause* »)** pourrait être envisagée sous condition de motiver et d'inclure une période de préavis minimale afin de permettre des transferts de joueurs ou remédier une situation urgente et consentie par les contractants (ne serait-ce que dans des cas spécifiques énumérés dans la loi).

4. D'autres alternatives

Si le contrat de prestation de services devait demeurer le contrat principalement utilisé dans l'industrie de l'esport, un régime fiscal préférentiel et des aides d'Etat pourrait inciter les acteurs à adopter des bonnes pratiques commerciales (*par ex.* la possibilité d'assurer au moins un paiement SMIC aux joueurs et les personnels de manière plus générale).

De même, une **option « *Opt-in* »** permettant aux employeurs d'accorder aux travailleurs, par leur propre bonne volonté, des aides et contributions sélectionnées (prévoyance, assurance, transport, repas, etc.), sans que ces éléments puissent requalifier le contrat de prestation de services en un CDI, pourrait contribuer à la protection des joueurs.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4125169